



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 30/12

התובעת:

מאיר רחל

ע"י ב"כ עו"ד י. מלמד ועו"ד ד. יורוביץ

- נ ג ד -

הנתבעים:

שלום יוסף ורוזה

ע"י ב"כ עו"ד א. שלום

פ ס ק - ד י נ

התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעים במסגרתה דרשה כי יינתן כנגדם צו מניעה קבוע האוסר עליהם להרחיב דירתם לעבר חזית הבית המשותף וגג הבית המשותף, וכן אוסר עליהם להקים גשרון מהחזית האחורית של הבית המשותף ישירות לדירתם. בנוסף דרשה התובעת בתביעתה כי אורה לנתבעים להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, ובכלל זה להרוס את הבנייה שהחלה על הגג ולשקם את הגינה והגדר שנהרסו כתוצאה מהתחלת העבודות.

פסק הדין עוסק בדרישות הנ"ל של התובעת, כאשר במסגרתו נבחנת השאלה מה היקף ההסכמה שעל הנתבעים לקבל לצורך העבודות המבוקשות על ידם, והאם יש בעבודות המבוקשות כדי לפגוע בתובעת באופן המחייב הסכמתה כתנאי לביצוען.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

א. העובדות הנדרשות לעניין והשתלשלות ההליך הדיוני

1. המדובר בבית המשותף בגוש 30143 חלקה 13 ברחוב יהודה הנשיא 21 בירושלים (להלן: **"הבית המשותף"**). בבית המשותף 4 דירות. התובעת היא בעלת הזכויות בדירה מס' 2 המצויה בקומת הקרקע, והנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה מס' 4 המצויה בקומה העליונה.
2. על פי צו הבית המשותף ותקנון הבית המשותף, הגג הינו רכוש משותף. כמו כן, כל שטח החצר הסובבת את הבית המשותף מהווה רכוש משותף, למעט קרקע בשטח של 124.66 מ"ר שהוצמד לדירה מס' 1 במסגרת תיקון צו בית משותף שבוצע בשנת 1977, ושעל חלק ממנו נבנתה תוספת לדירה מס' 1 [ר' צו רישום הבית המשותף מיום 16.11.60 וצו רישום הבית המשותף מיום 6.11.77].
3. הנתבעים רכשו את דירתם לפני מספר שנים ובסמוך לכך הם החלו לקדם תכנית להרחבת דירתם. התכנית כללה הרחבת הדירה לעבר חזית הבית המשותף ובניית קומה נוספת על הגג. כמו כן, ביקשו הנתבעים במסגרת התכנית כי השטח שייווצר מעל ההרחבה המתוכננת בחזית ישמש כמרפסת לדירתם. בנוסף כללה התכנית גם בקשה לבניית גשרון בצדו האחורי של הבית המשותף שנועד לאפשר כניסה ישירה לדירת הנתבעים [ר' תכניות הבניה שצורפו כנספח 1 לתצהיר גב' יעל שלום].
4. בין הצדדים התגלעו מחלוקות קנייניות ותכנוניות רבות, והם ניהלו במקביל הליכים משפטיים בפני ועדות התכנון והבנייה ובפני.
5. על אף כל ניסיונותי לא עלה בידי להביא את הצדדים לעמק השווה, ולפיכך לא היה מנוס מקביעת התיק להוכחות.
6. בימים 24.9.12, 24.1.13, 24.4.13, 7.5.13, 1.10.13 נשמעו עדי הצדדים והמומחים מטעמם, ולאחר מכן סיכמו הצדדים טיעוניהם בכתב.
7. לאחר הגשת הסיכומים נעשה מאמץ נוסף להביא את הצדדים לכלל הסכמה, ואולם ניסיון זה לא רק שלא צלח אלא גם הציף סוגיה נוספת שדרשה ליבון. בעקבות זאת נקבע התיק להשלמת הגשת ראיות וטיעונים.
8. בטרם סיימו הצדדים השלמת טיעוניהם כאמור, הודיעו הנתבעים ביום 9.12.14 כי בעקבות אירועים כאלה ואחרים שפקדו אותם הם חוזרים בהם מכוונתם לבנות בחזית הבית המשותף, ומבקשים אך ורק להרחיב את דירתם על הגג בשטח כולל של 47 מ"ר, וכן לבנות



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

את הגשרון בהתאם להיתר הבניה. בנסיבות אלו בקשו התובעים כי יינתן פסק דין המתיר להם להשלים רק את הבנייה כאמור.

9. גם לדרישה זו התנגדה התובעת, ולפיכך לא נותר לי אלא ליתן פסק דין בנושאים שנותרו במחלוקת.

ב. היקף יריעת המחלוקת – הנושאים בהם יעסוק פסק הדין

10. כאמור לעיל, הנתבעים הודיעו כי הם אינם מעוניינים לבנות בחזית הבית המשותף ומבקשים לצמצם את המחלוקת רק בנוגע להרחבה המבוקשת על הגג, ובנוגע לבקשתם לבנות את הגשרון.

11. מובן, כי נוכח הודעה זו של הנתבעים מתייטר הצורך לדון בסוגיית הבנייה בחזית הבית המשותף, ואין לי אלא ליתן צו, בהתאם להודעת הנתבעים, האוסר עליהם לבנות בחזית הבית המשותף על פי היתר הבניה שהוצג בהליך, ללא שקיבלו את הסכמת התובעת לכך.

12. נותרו אפוא שני נושאים שעלי להכריע בהם: דרישת הנתבעים להרחיב דירתם על גג הבית המשותף, ודרישתם לבנות גשרון שיוביל ישירות לדירתם.

13. אפרט אפוא את טענות הצדדים רק ביחס לשני הנושאים הללו, ולאחר מכן אכריע בדבר.

ג. טענות התובעת בקצרה

14. בראש ובראשונה נטען על ידי התובעת כי בתקנון המוסכם משנת 1977 קיימת הוראה מפורשת שלפיה בעלי הדירות נדרשים לקבל את הסכמתם המפורשת של כל יתר בעלי הדירות, כתנאי לביצוע בנייה כלשהי. לאור זאת, ומאחר שהתובעת מתנגדת לבנייה המבוקשת, הרי שאין בידי הנתבעים את ההסכמות הדרושות כדי לבצע את ההרחבה.

15. בעניין זה הדגישה התובעת כי ההסכמה שהוענקה על ידה בתחילת הדרך הוצאה ממנה במרמה, והתייחסה רק לחלק קטן מהבנייה המבוקשת כיום. התובעת הפנתה בעניין זה לעדויות בנותיה, והדגישה כי בעוד שעדותן בנושא זה היתה עקבית ומפורטת, העדה שהעידה מטעם הנתבעים בנוגע לכך, גבי יעל שלום, לא טיפלה בנושא הרלוונטי וממילא לא יכולה היתה להעיד על מה היא חתמה. התובעת הפנתה גם למכתבים שנשלחו לב"כ הנתבעים, במסגרתם נטען על ידה כי טרם הבנייה יש לבוא עימה בדברים הן ביחס לבנייה על הגג, הן ביחס לגשרון המוצע והן ביחס למעטפת שאמורה היתה להיבנות בדירתה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

16. יתרה מכך, כך לשיטת התובעת, גם אם ייקבע שחלות על ענייננו הוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הקובע שדי ברוב של שלושה רבעים כדי לאפשר את הרחבת דירת הנתבעים, הרי שהוכח שאין בידי הנתבעים את הרוב האמור. לטענת התובעת, ההסכמות שהציגו הנתבעים הוצגו רק לאחר הגשת התביעה, ויתרה מכך, הוכח כי אף הן התקבלו במרמה, וכי הלכה למעשה בידי הנתבעים, לכל היותר, הסכמתם של 37.5% מבעלי הדירות. בעניין זה מסתמכת התובעת על עדותו של מר בן ישי ממנה מבקשת היא ללמוד כי הוא הסכים לבנייה רק בתנאי שלא תיפגענה זכויות התובעת, וכן לעדותה של רעייתו, גב' בן ישי, שהעידה כי אין היא מעוניינת להתערב בסכסוך. התובעת הפנתה גם לעדותה של גב' טל שהעידה, לטענתה, כי היא חוזרת בה מהסכמתה וכי ההסכמה ניתנה תוך הפעלת לחצים על ידי הנתבעים, וכן לעדותו של בן זוגה שהעיד כי אין לו התנגדות לבנייה רק בכפוף לכך שהיא תבוצע בהתאם להחלטת ועדת הערר.
17. הוסיפה התובעת, כי אין מקום לטענת הנתבעים כי יש לראות את בעלי הדירות האחרים (מלבד התובעת) כמי שביצעו הרחבה דומה. לשיטתה, איש מבעלי הדירות לא בנה גשרון או הרחיב דירתו על גג הבית המשותף, ומכאן שבודאי שבכל הנוגע לנושאים אלו אין לראות במי מהדיירים כמסכימים לבנייה המבוקשת. התובעת טענה גם כי טענה זו בדבר "הרחבה דומה" נטענה על ידי הנתבעים רק ביחס לדירתם של ה"ה טל, ומכאן שלכל היותר רק ביחס אליהם ניתן להעלות טענה זו כעת. כן הוסיפה התובעת כי הבנייה שביצעו ה"ה טל אינה דומה כלל ועיקר לבנייה המבוקשת על ידי הנתבעים, שכן בעוד שההרחבה שביצעו ה"ה טל נבנתה על חצר שהוחזקה מאז ומעולם על ידם, מבקשים הנתבעים ליטול לעצמם את גג הבית המשותף ששימש זה שנים את כלל בעלי הדירות. בנוסף, כך הסבירה התובעת, בבנייה שמבקשים הנתבעים לבצע על גג הבית המשותף יש כדי למנוע ממנה בעתיד לנצל את זכויותיה, וגם בכך שונים הדברים באופן מהותי מהבניה שבוצעה על ידי ה"ה טל.
18. התובעת טענה גם כי אין לראות במחסן שבנתה היא עצמה סמוך לדירתה "הרחבה דומה", הן נוכח היקפו הקטן יחסית והן נוכח מיקומו.
19. לטענת התובעת, אין להתיר לנתבעים לבצע הבניה ולו בשל הפגיעה שתיגרם לה בעתיד. לטענתה, מאחר שלכל דירה מוענקות זכויות בנייה בשיעור של למעלה מ- 125 מ"ר לצורך הרחבת הדירה, הרי שהיא תוכל לנצל את מלוא הזכויות המוענקות לה רק אם תרחיב דירתה לקומת המסד. דא עקא, שהוראות התב"ע החלה על המקום מגבילות את מספר הקומות בבית, ולפיכך היה ויבנו הנתבעים קומה נוספת על גג הבית המשותף, לא יותר לה בעתיד לבנות קומת מסד. בניה על הגג על ידי הנתבעים בהתאם לתכנית הבנייה שהגישו, כך לטענת התובעת, תביא אפוא בהכרח לנטילת זכויות הבנייה השייכות לה, ולפיכך אין להתירה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

20. התובעת הוסיפה וטענה כי הבניה על הגג על ידי הנתבעים תמנע את האפשרות לממש זכות כלשהי בגג, בין היתר לצורך בניית דירה נפרדת ממנה ייהנו כל בעלי הדירות בבית. לטענת התובעת מדובר בפגיעה קשה שאין להתירה. כן טענה התובעת כי הבניה המבוקשת על ידי הנתבעים תשנה את חזיתו של הבית המשותף.
21. התובעת מתנגדת כאמור גם לבניית הגשרון. לטענתה, הגשרון יצל על דירתה ואף יגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהרכוש המשותף. התובעת טוענת גם כי הגשרון ישנה ויכער את פני הרכוש המשותף, ולכן יש לקבל את הסכמת כל יתר בעלי הדירות כתנאי לבנייתו.
22. התובעת הטילה ספק של ממש בטענת הנתבעים שלפיה הגשרון נועד לאפשר להם להגיע לדירתם בשל המגבלות הרפואיות של הנתבע מס' 1, תוך שהיא הפנתה לכך שבתכנית הבנייה המבוקשת מתוכננות מדרגות בתוך הדירה. כן טענה התובעת כי גם אם הדבר נחוץ לנתבעים, הרי שניתן לבנות במקום מעליון שייפגע פחות בחזות הבית המשותף.
23. בסיכומיה הוסיפה התובעת כי לכל אורך הדרך התנהלו הנתבעים בחוסר תום לב, בחרו להפר את ההסכמות שהיו בבסיס הדברים ולא לשתף פעולה עם התובעת. בנסיבות אלו, כך טוענת התובעת, אין מקום לטענת ההסתמכות שמעלים הנתבעים, וודאי שלא לטענות בדבר נזק שנגרם להם לכאורה.
24. בסיכומי תשובתה טענה התובעת כי סיכומי הנתבעים לוקים בהרחבת חזית אסורה במגוון נושאים, ובכלל זה בפרשנות תקנון הבית המשותף ובהסכמות השכנים. כן טענה התובעת בסיכומי תשובתה כי הנתבעים הסתמכו על ראיות אסורות ויש לפסלן. בנוסף, מאשימה התובעת את הנתבעים במעשי מרמה וזיוף.
25. לאור כל האמור, דרשה התובעת כי יינתן צו המורה לנתבעים להרוס כל בנייה שבנו ולהשיב את המצב לקדמותו. כן דרשה התובעת כי יינתן כנגד הנתבעים צו מניעה קבוע האוסר עליהם לבנות את המבוקש על ידם.

ד. טענות הנתבעים בקצרה

26. לטענת הנתבעים מאחר שמדובר בהרחבת דירה, הרי שדי ברוב של 75% מבעלי הדירות כפי שנקבע בסעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**"). לטענתם, אין בתקנון המוסכם משנת 1977 כדי לשנות מהוראות סעיף זה, שכן ההוראה בתקנון שעליה מסתמכת התובעת נוגעת להרחבה שתיעשה בדירת משפחת טל שהרחיבה דירתה בעבר, ואינה מתייחסת ליתר הדירות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

27. לשיטת הנתבעים, בידם הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 71ב לחוק. לטענתם, הוכח שבעלי הדירות של שתי דירות נוספות בבית המשותף, ה"ה טל וה"ה בן ישי, חתמו על הסכמתם לבנייה, ואף היום הם מסכימים לכך. בעניין זה הפנו הנתבעים לנספח 1 לתצהירה של גב' שלום וכן לנספחים 4-7 לתצהירה המשלים, המעידים לטענתם על ההסכמה כאמור. כן הפנו הנתבעים לעדויות ה"ה בן ישי וה"ה טל במסגרת ההליך, שהעידו כי הם הסכימו לבנייה המבוקשת.
28. בסיכומיהם הדגישו הנתבעים כי אין כל אמת בטענת התובעת שלפיה חתימת מי מבעלי הדירות בוצעה בכפייה. בהקשר לכך הפנו הנתבעים בין היתר לעדות בנם של ה"ה טל וכן לעדות מר טל עצמו שהעידו כי חתמו לאחר שבחנו את הדבר לעומקו והסכימו לכך. הנתבעים טענו גם כי אין אמת בטענת התובעת שלפיה חלק מבעלי הדירות חזרו מהסכמתם, והסבירו כי המסמך שנחזה להיות כחזרת הגב' בתיה בן ישי מחתימתה (נספח 33 לתצהיר התובעת) הינו בגדר עדות שמיעה, ומכל מקום לא ניתן ללמוד ממנו כי גב' בן ישי מתנגדת לבניה. יתרה מזאת, כך לטענת הנתבעים, גם אם היה ממש בטענות התובעת בדבר חזרה של מי מבעלי הדירות מחתימתו על הסכמה לבניה, הרי שיש לדחות חזרה מהסכמה זו נוכח העובדה שהנתבעים הסתמכו על ההסכמה שהוענקה להם ושינו מצבם.
29. הנתבעים הוסיפו כי בכל מקרה יש לראות בבעלי הדירות הללו (ה"ה טל ובן ישי) כמי שנתנו הסכמתם לבנייה המבוקשת, וזאת מכח סעיף 71ב(ג) לחוק. לטענתם, הוכח שבדירות אלו בוצעה הרחבה דומה לזו שמבקשים הנתבעים לבצע, כאשר בעניין זה הם מפנים לחוות דעתו ועדותו של המודד אברהם ארנסטר שקבע כי בדירה מס' 1 (טל) נמדדו 128 מ"ר בנוי ללא התוספת וללא מרפסת חיצונית על עמודים, לתקנון הבית המשותף שקבע כי דירת ה"ה טל הורחבה ל-124.66 מ"ר, ולעדותו של ה"ה בן ישי שהעיד כי "שטח הדירה שלנו לאחר ההרחבה הוא 145 מ"ר". (עמוד 1 שורה 42 לפרוטוקול מיום 16.5.12).
30. לשיטת הנתבעים מאחר שהוכח כי בעלי הדירות בשתי דירות אחרות נתנו הסכמתם לבניה המבוקשת על ידם, הרי שיחד עם הנתבעים עצמם, קיים רוב של 75% מבעלי הדירות המסכימים להרחבה.
31. בכל הנוגע לדרישת הנתבעים לבנות את הגשרון, מסתמכים הנתבעים על הוראותיו של סעיף 59 לחוק המקרקעין, תוך שהם מפנים לאישור הרפואי שצירפו לתצהירהם הקובע כי הנתבע מס' 1 סובל מאי ספיקת לב ומבעיות רפואיות נוספות.
32. בסיכומיהם טענו הנתבעים גם כי התובעת עצמה הסכימה לבנייה המבוקשת, ורק בנותיה שניהלו את ההליך הן שמתנגדות לכך. בהקשר זה הפנו הנתבעים לכך שהתובעת עצמה לא באה להעיד ולהזים את העדויות מטעמם כי ניתנה על ידה הסכמה, וכן לעדות בתה של



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

התובעת שהודתה כי חתמה על הסכמה לבניה וחזרה בה לאחר מכן. לשיטתם, מנועה התובעת לחזור בה מהסכמתה שכן הם הסתמכו עליה והוציאו כספים מרובים על בסיסה.

33. הנתבעים סבורים גם כי יש לראות בתובעת כמי שמסכימה לבנייה מכח הרחבה דומה שביצעה בעבר, כאשר בעניין זה נטען על ידם כי יש לראות במחסן שבנתה התובעת בחצר, וכן בהשתלטותה על שטח נוסף בחצר, כהרחבה דומה לזו המבוקשת על ידם.

34. בכל הנוגע לטענות התובעת בדבר נטילת זכויות הבנייה השייכות לה טוענים הנתבעים בסיכומיהם, כי מדובר בתכנית בניין עיר מיוחדת שבמסגרתה מוקצות זכויות בנייה בשיעור של 125 מ"ר לכל דירה בנפרד. לשיטתם, מאחר שזכויות הבנייה מוקצות לכל בעל דירה בנפרד, הרי שניצולן על ידי בעל דירה אחד אינו משפיע ואינו יכול לגרום לפגיעה בזכויות הבנייה של בעלי הדירות האחרים. הנתבעים שבים ומדגשים בסיכומיהם כי דרישתם לבנות 125 מ"ר אינה אלא בקשתם לניצול זכויות הבנייה המוקנות להם, כאשר האפשרות היחידה לניצולן היא בבנייה המשתרעת גם על גג הבית המשותף.

35. לטענת הנתבעים, אין גם אמת בטענת התובעת שלפיה בנייה על הגג תביא בהכרח לכך שהתובעת לא תוכל לנצל את זכויות הבנייה המוקצות לה באמצעות בנייה במסד הבית המשותף. הנתבעים אינם חולקים על טענת התובעת בדבר מגבלת הגובה הקבועה בתב"ע, אך סבורים כי היא מתייחסת ל"חתך" אחד, ולפיכך רשאית התובעת לבנות בכל מקום שאינו מקביל לבנייה המבוקשת על הגג. בהקשר לכך מפנים הנתבעים לתשריט שהכין האדריכל רוזנבלום והוגש במהלך חקירתו [מש/3] ממנו עלה כי קיימת אפשרות להרחבת דירת התובעת בהתאם למלוא אחוזי הבנייה המוקנים לה, וכן לעדותו של מר פינצי מעיריית ירושלים שקבע כי מגבלת הקומות נוגעת ל"חתכים", וכי אין במגבלת הקומות כדי למנוע בניית ממ"ד בקומה נוספת. הנתבעים מפנים גם לעדותו של מר יזרעאלי, אדריכל התובעת, שהודה כי התובעת יכולה לבנות עד 130.38 מ"ר, ואף למעלה מכך, וזאת גם אם הבנייה על הגג תאושר. הנתבעים התייחסו גם לטענות התובעת בדבר הקושי הרב וחוסר הכדאיות שיש בבניה במסד הבית המשותף, וטענו כי אם אכן זה המצב הרי שברור כי לא הבנייה על הגג היא שתמנע מהתובעת לבנות במסד הבית המשותף, אלא תנאי השטח.

36. לטענת הנתבעים אין כלל מקום לטענות התובעת בדבר פגיעה באפשרותה להקים יחידת דיור נוספת על הגג, מאחר שהתב"ע החלה על המקום מתירה לנצל את אחוזי הבניה לצורך הרחבת הדירות בלבד. הנתבעים הפנו בעניין זה גם להלכה שנקבעה בע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא (ניתן ביום 2.8.12 פורסם בנבו), שלפיה בנייה שאינה סמוכה לדירה אינה בגדר "הרחבת דירה".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

37. בכל הנוגע לטענת התובעת בעניין פגיעה בחזית הבית המשותף ובעניין הפגיעה שתיגרם לה עקב בנית הגשרון, הפנו הנתבעים להחלטת ועדת הערר לתכנון ולבניה שדחתה טענות אלו לחלוטין, לא לפני שביקרה במקום והתרשמה מהמצב העובדתי בשטח. כן טענו הנתבעים בעניין זה כי עדות האדריכל יזרעאלי שטען כי הגשר יטיל צל על חלון התובעת הופרכה, שכן הוא התייחס לחלון שכלל לא קיים עוד בדירת התובעת. בעניין זה טענו הנתבעים גם כי התובעת אינה רשאית לטעון להחשכת המבנה המצוי בעורף הבית המשותף, נוכח העובדה שמבנה זה כשלעצמו לא חוקי.

38. הנתבעים הקדישו בסיכומיהם פרק ניכר לטענותיהם בדבר רצונם לרצות את התובעת ולהיעתר לדרישותיה גם לאחר חזרתה לטענתם מהסכמתה, ולפגישות הרבות שהתקיימו בין הצדדים בנוכחות גורמים שונים כדי לנסות ולהגיע לעמק השווה. הנתבעים טענו גם לשיהוי בהגשת התביעה, לחוסר תום לב מצד התובעת, ושימוש לרעה בהליכי משפט. כן טענו הנתבעים בסיכומיהם כי יש לאשר את הבנייה המבוקשת על ידם מכח עקרונות תום הלב ונוכח הוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין.

39. לאור כל האמור דרשו הנתבעים כי אורה על דחיית התביעה בכל הנוגע לנושאים שנותרו במחלוקת, ואחייב את התובעת בהוצאותיהם.

ה. דיון והכרעה

40. כדי להכריע בסוגיות שנותרו במחלוקת עלי להידרש לשלוש שאלות עיקריות:

41. השאלה הראשונה שעלי להכריע בה היא מהו הרוב הדרוש לנתבעים כדי לבצע את הבנייה המבוקשת על הגג וכדי לבצע את בניית הגשרון – האם, כפי שטוענת התובעת, נוכח הוראות התקנון המוסכם, על הנתבעים לקבל את הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית המשותף, או שמא, כפי שנטען על ידי הנתבעים, אין בתקנון כדי לשנות מהרוב הקבוע בסעיף 71 לחוק, ודי ברוב של שלושה רבעים מבעלי הדירות.

42. לאחר מכן, ובהתאם לתשובה לשאלה הראשונה, עלי לבחון האם בידי הנתבעים קיימות ההסכמות הדרושות. מובן, כי ככל שאקבע כי היה על הנתבעים לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות, ובכללם התובעת, יהיה עלי לבחון האם יש לראות בתובעת כמי שמסכימה לבנייה. לעומת זאת, ככל שאגיע למסקנה כי די ברוב הנקוב בסעיף 71 לחוק, וכן אגיע למסקנה כי יש לראות ביתר בעלי הדירות כמי שהעניקו הסכמתם, יתייתר הצורך לדון בשאלת הסכמתה של התובעת עצמה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

43. ולבסוף, ככל שאמצא כי בידי הנתבעים ההסכמות הדרושות לביצוע הבנייה, יהא עלי לבחון האם תיגרם לתובעת פגיעה מהותית, המקימה לה "זכות וטו" להתנגד לבנייה המבוקשת.

44. אדון בשאלות הללו אחת לאחת, כאשר בתחילת הדברים אתייחס לבנייה שמטרתה הרחבת דירת הנתבעים על גג הבית המשותף, ולאחר מכן אדון בבקשת הנתבעים לבנות גשרון לדירתם.

45. **מהו הרוב הדרוש להרחבה אותה מבקשים הנתבעים לבצע על הגג**

46. הכלל הבסיסי בכל הנוגע להצמדת חלק מהרכוש המשותף על ידי בעל דירה מסוימת לדירתו, חקוק בסעיף 62 לחוק המקרקעין הקובע כי: **"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**. (ההדגשה לא במקור).

47. ברבות השנים ביקש המחוקק להקל על מצוקת הדיור באמצעות הצמדתם של שטחים מהרכוש המשותף לדירות הבית המשותף. לצורך כך קיבל המחוקק את תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין, אשר צמצם את הרוב הנדרש בסעיף 62 לחוק לשם הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, במקרה שבו ההצמדה נועדה להרחבת הדירה [לעניין תכלית תיקון מס' 18 לחוק ר' סיכום הדברים המובאים ברע"א 1462/10 דוד עטיה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו, 2.8.2012)].

48. וכך נקבע בסעיף 71ב(א) לחוק שהוסף במסגרת תיקון מס' 18 הנ"ל:

על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה...

49. במסגרת התיקון הנ"ל, נחקק גם סעיף 71ד לחוק הקובע כי:

(א) בעלי הדירות בבית משותף רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סימן זה לא יחולו עליהם.
(ב) אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר הרחבת דירה או זכויות בניה. (ההדגשה לא במקור).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

50. הנה כי כן, בהתאם לסעיף 71ב לחוק, מקום בו בעל דירה מבקש לקבל לעצמו לצמיתות חלק מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירתו, הוא רשאי לעשות כן בכפוף לקבלת הרוב הקבוע בסעיף 71ב(א) לחוק, זולת במקרה שבו קיימת הוראה מיוחדת בתקנון המוסכם של הבית המשותף, שאז כפוף הוא לאותה הוראה מיוחדת.

51. שורש המחלוקת בין הצדדים בעניין הרוב הנחוץ להרחבת דירה הנתבעים במקרה דנן, נעוץ בתקנון המוסכם שנרשם ביום 6.11.77. לשיטת התובעת יש בתקנון זה הוראה מיוחדת המותירה את הכלל הקבוע בסעיף 62 לחוק שלפיו דרושה הסכמת כל בעלי הדירות לשם הצמדת חלק מסוים לדירת הנתבעים, ומנגד טוענים הנתבעים כי אין בהוראות התקנון כדי לפגום בתחולת הוראות סעיף 71ב(א) לחוק, ולפיכך די ברוב הקבוע בו כדי לאפשר להם להרחיב את דירתם.

52. התקנון המוסכם שנרשם ביום 6.11.77 קובע כדלקמן:

אנו הח"מ בעלי הזכויות בדירות בחלקה 13 בגוש 30143 ירושלים, מבקשים
בזה לרשום תקנון ולראות בקשה זו כתקנון מוסכם שפרטיו כדלהלן:

1. מאחר ובעלי יחידה 13/1 בנו תוספת לדירה המוחזקת על ידם על שטח כולל של 124.66 ממ"ר בהתאם להסכמת יתר בעלי היחידות מיום 16.9.71, מוסכם בזה כי שטח של 124.66 ממ"ר המסומן בצבע אדום בתסריט המצורף לתקנון זה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו, יוצא מהרכוש המשותף ויוצמד בצמידות מיוחדת ליחידה 13/1.
2. ...
3. למרות האמור לעיל, הזכות ברכוש המשותף לכל דירה תהיה 3/4 חלקים בלא יחס לשטח הרצפה.
4. על כל היחידות בבית המשותף יחולו הוראות החוק והתוספות לחוק. ההוראות דלהלן מכוונות להוסיף ולא לגרוע מהן ובאות לשנות רק במידה ובמקרה שאין לישיב את הכתוב להלן עם הוראות החוק או התקנון שבתוספת הנ"ל.
5. בכפוף לאמור להלן זכאי כל בעל יחידה להנות מיחידתו הוא (כולל כל חלק הצמוד לה בצמידות מיוחדת אם יש חלק כזה), וכן זכאי הוא להנות באופן מתקבל על הדעת מהרכוש המשותף.
6. ...
7. מאחר שבעל יחידה 13/1 בנה תוספת ליחידתו כאמור לעיל, מוסכם בזה כי רישום תיאור הדירה ישונה בהתאם לתוספת שנבנתה ובהתאם לחלוקה הפנימית שנעשתה, הכל לפי התכנית שאושרה ע"י בעלי יתר היחידות ורשויות הרישוי.
8. לכל בניה נוספת תידרש הסכמת כל יתר בעלי היחידות בבנין.
9. ...



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

53. המחלוקת בין הצדדים נוגעת כמובן לסעיף 8 לתקנון. לדידה של התובעת סעיף מהווה הוראה מיוחדת הקובעת שכל הרחבה נוספת של דירה על הרכוש המשותף, תהא אשר תהא, דורשת את הסכמתם של כל בעלי הדירות, ולעומת זאת לשיטת הנתבעים סעיף זה מתייחס לבניה נוספת בדירה מס' 1 שכבר הורחבה בעבר, אך לא ליתר בעלי הדירות שלגביהם אין הוראה מיוחדת.
54. עלי להידרש אפוא, לפרשנותו של התקנון המוסכם ולסעיף 8 לו.
55. להווי ידוע, כי התקנון מהווה הסכם בין בעלי הדירות בבית המשותף, ולפיכך מלאכת פרשנותו היא כמלאכת פרשנותו של כל הסכם בין צדדים [ר' למשל ע"א 5043/96 **נחמיה גלמן נ' הררי רפול עזרא**, פ"ד נד(3), 389]. בתוך כך, עלינו לתור אחר אומד דעת הצדדים בעת עריכת התקנון, כאשר על פי ההלכה הפסוקה אומד דעת הצדדים נבחן מתוך לשונו של המסמך הקונקרטי, תכליתו, והנסיבות האופפות את עריכתו. [ר' ע"א 3894/11, **דלק - חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן-שלום** (פורסם בתקדין, ניתן ביום 6.6.13)].
56. על רקע האמור נבחן את המקרה דנן.
57. לשונו של סעיף 8 לתקנון סובל את שני הפירושים המוצעים, שכן לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי האם ההגבלה המופיעה בו מתייחסת ל"בניה נוספת" של בעל דירה מס' 1 (שהרחבת דירתו היתה הסיבה לתיקון התקנון), או שמא מתייחסת היא לכל בעלי הדירות. עם זאת, סבורני כי בחינת הקשרו של הסעיף עם יתר סעיפי התקנון, כמו גם נסיבות עריכתו והתכלית שלשמה הוא נערך, מביאים למסקנה כי יש להעדיף את פרשנות הנתבעים שלפיה סעיף 8 לתקנון מתייחס לבעלי הזכויות בדירה מס' 1 בלבד.
58. ראשית, משום שעיון בתקנון מלמד כי סעיף 8 אינו עומד בפני עצמו, אלא הוא מהווה המשכו הישיר של סעיף 7 העוסק בבנייה שביצעו בעלי הזכויות בדירה מס' 1. מכאן, שסעיף 8 לא נועד להתנות כל בנייה בבית המשותף בהסכמת כל בעלי הזכויות, אלא רק בנייה נוספת של בעל דירה מס' 1 אשר כבר בנה ברכוש המשותף.
59. יתרה מכך והוא עיקר – כפי שעולה מהתקנון המוסכם עצמו, הוא נערך בעקבות הרחבה שביצע בעל דירה מס' 1 בהיקף של כ- 125 מ"ר (ר' סעיף 1 לתקנון). אך טבעי הוא כי במסגרת הסכמת יתר בעלי הדירות לתוספת הבנייה בדירה מס' 1, הם ביקשו לוודא שלא ניתן יהיה לבצע הרחבה נוספת בדירה זו ללא הסכמתם. מנגד, אין זה מתקבל על הדעת שיתר בעלי הדירות גם הסכימו להרחבה שבוצעה בדירה מס' 1, וגם בקשו להרע את זכויותיהם, ולהוסיף הוראה מיוחדת הקובעת שכאשר הם יבקשו להרחיב את דירתם הם יהיו כפופים, בכל מקרה, להסכמת כל בעלי הדירות. המסקנה המתחייבת היא אפוא כי



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

סעיף 8 נועד אך ורק כדי להגביל את זכותם של בעלי הזכויות בדירה מס' 1 להרחבה נוספת, ולכך בלבד.

60. ודוק: הפרשנות המוצעת וקריאת סעיף 8 לתקנון כהמשכו של סעיף 7, מסבירה גם מדוע קבעו הצדדים בסעיף 8 לתקנון כי כל בניה נוספת תדרוש את הסכמתם של "כל יתר בעלי היחידות" (ההדגשה לא במקור). לכאורה, לו אכן התכוונו עורכי התקנון לקבוע כי כל בניה תדרוש הסכמת כל הבעלים לא היה צורך במילה "יתר". מכאן ראייה נוספת לכך שמטרת הצדדים בסעיף 8 לתקנון היתה למנוע הרחבה נוספת בדירה מס' 1 שכבר הורחבה.

61. נוכח כל המוסבר מסקנתי היא כי סעיף 8 לתקנון מתייחס לדירה מס' 1 בלבד, ואילו ביחס ליתר הדירות בבית המשותף שטרם הורחבה דירתם אין הוראה מיוחדת כלשהי בתקנון.

62. פועל יוצא מכך הוא שסעיף 71ב(א) לחוק חל על הרחבת דירת הנתבעים, ולפיכך כדי שיאושר להם להרחיב דירתם די בכך שיוכיחו כי קיבלו את הסכמותיהם של שלושה רבעים מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

63. אבחן עתה האם בידי הנתבעים הרוב הדרוש הנ"ל.

האם במקרה דנן קיבלו הנתבעים את ההסכמות הנדרשות להרחבה על הגג

64. בטרם אבחן את ההסכמות לגופן חשוב להזכיר כי הלכה היא שיש לבחון את מתן ההסכמות נכון למועד הדיון בתובענה, ואין הכרח להוכיח כי הן היו בידי מבקש ההרחבה בעת בקשתו להיתר או בעת הבניה [ר' למשל רע"א 527/14 **כובאני נ' לוי** (פורסם בנבו, 19.2.14)]. משכך, עלי לבחון האם נכון להיום בידי הנתבעים ההסכמות הדרושות.

65. בבית המשותף 4 דירות, ועל פי התקנון המוסכם לכל אחת מהדירות צמוד 1/4 מהרכוש המשותף. מובן אפוא כי ככל שיוכח כי בעלי הדירות 1,3 מסכימים לבנייה, אין אלא לקבוע כי בידי הנתבעים הרוב הדרוש.

66. כפי שעולה מנסח רישום הבית המשותף בעלי הזכויות בדירה מס' 1 הם ה"ה בנימין ועדנה טל. בדירה מס' 1 בוצעה בעבר הרחבה בהיקף של כ- 70 מ"ר לפחות ואף הוצמד לה שטח נוסף [כיום הדירה רשומה בשטח של 100 מ"ר במקום 34.01 מ"ר; ר' גם צו הבית המשותף, ותקנון הבית המשותף משנת 1977].

67. בדירה מס' 3, ששטחה הרשום הוא 34.01 מ"ר, רשומים כבעלי זכויות ה"ה בן ישי דוד ובן ישי בתיה. מעדותו של מר בן ישי עלה כי שטח דירתו כיום הוא 145 מ"ר, ומכאן שגם דירה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

זו הורחבה בעשרות מ"ר [ר' פרוטוקול הדיון מיום 16.5.12 בעמוד 1 שורה 42; ר' גם סעיף 5 לתע"צ שהוגשה מטעם נציג עיריית ירושלים, מר פינצ'ין].

69. על פי סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין: **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**. לאור הוראה זו, ומאחר שההרחבה אותה מבקשים כיום הנתבעים לבצע משתרעת על שטח שאינו עולה על 50 מ"ר, ונוכח ההרחבות הקיימות כאמור בדירות 1 ו-3, הרי שאין ספק כי יש לראות בבעלי הזכויות בדירות אלו כמי שביצעו "הרחבה דומה" במובנו של סעיף 71ב(ג) לחוק, וכמי שמסכימים להרחבה המבוקשת על ידי הנתבעים.

70. זה המקום לציין, כי איני מקבל את ניסיונה של התובעת לבצע הבחנה בין ההרחבות שבוצעו בדירות 1 ו-3 לבין הבנייה שמבקשים הנתבעים לבצע. לא פעם נקבע כי לא בכדי נקט המחוקק בסעיף 71ב(ג) לחוק במונח **"הרחבה דומה"** ולא במונח **"הרחבה זהה"**, וכפי שהסביר זאת המלומד אייזנשטיין [א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיי מקרקעין, חלק ג', 234]: **"ראוי להדגיש כי סעיף 71ב(ג) הנ"ל מתייחס להרחבה דומה, כלומר, רואים את מי שדירתו הורחבה בגודל מסוים כמי שהסכים להרחבה של כל דירה אחרת שתהיה בגודל דומה להרחבה שאושרה לו. הגודל הדומה אינו חייב להיות בהכרח מדויק ושווה, אלא יכול להיות גודל דומה ושווה בקירוב"**. [ר' גם פסק הדין בעש"א (מחוזי חי) 22123-10-10, **חדד נ' זינגר**, (פורסם באתר נבו)].

71. אשר על כן, אין לי אלא לקבוע כי בידי הנתבעים הרוב הדרוש להם לצורך הרחבת דירתם על הגג.

72. למעלה מהדרוש אוסיף כי הוכח גם שבעלי הזכויות בדירות 1 ו-3 הסכימו לבנייה המבוקשת.

73. בעלי הזכויות בדירה מס' 3, ה"ה בן ישי, חתמו על תכניות הבניה ששימשו בסיס להיתר הבניה, ובה מפורטת הבניה המבוקשת בחזית ובגג [ר' נספח 1 לתצהיר הנתבעים]. בנוסף, נתנו ה"ה בן ישי את הסכמתם המפורשת לבנייה המבוקשת על ידי הנתבעים בהודעה בכתב מיום 4.12.12 ומיום 3.12.12 [ר' נספחים 4-5 לתצהיר הנתבעים].

74. זאת ועוד, במסגרת הדיון בצו המניעה העיד מר בן ישי כדלקמן [ר' עמודים 2-3 לפרוטוקול הדיון מיום 16.5.12]:

ת. לגבי הבניה של משפחת שלום, אני אומר שבהצלחה שיהיה לכם, ושתבנו מבלי לפגוע בזכויות של גב' רחל.

ובהמשך –



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ת. בפגישה שנפגשנו...דיברנו שאני מאשר לבנות את תוספת הבנייה ואין לי התנגדות. בסופו של דבר חתמתי, כמובן.

ת. לגבי מה שאתה מפנה אותי כתב ההסכמה שצורף לתצהיר חתמתי מרצון כמובן..."

ת. לגבי התכנית שאתה מראה לי נספח ד' להודעה אני חתמתי בלי לפגוע בזכויות של המבקשות אני מבהיר שאני חותם מבחינתי, אבל אם הוא חורג מזכויות הבניה שלו ופוגע בזכויות המבקשת כמובן שהם צריכים להגיע להסדר ביניהם. אני לא מתנגד לבנייה שלו.

כך גם ענה העד במענה לשאלת ב"כ התובעת -

ת. אני לא מתנגד לבנייה. נקודה. היא לא נפגעת...

75. גם הגב' בן ישי נחקרה בדיון על ידי ב"כ התובעת [ר' פרוטוקול הדיון הנ"ל בעמוד 4], ובסופו של דבר הודיעה כי:

ת. אין לי התנגדות שהם בונים. אני מסכימה לבנייה כל עוד לא מפריעים לי. אני מקווה שהם יסתדרו.

76. אין אפוא מקום לספק כי ה"ה בן ישי הסכימו מפורשות לבנייה.

77. אף את בעלי הזכויות בדירה מס' 1, ה"ה טל, יש לראות כמי שהסכימו מפורשות לבנייה, שכן הם חתמו על תכניות הבנייה [ר' נספח 1 לתצהירה של גב' שלום וכן עדותה של גב' טל בפרוטוקול הדיון מיום 16.5.12 עמוד 4 שורות 34-45]. אמנם, נטען על ידי התובעת כי ה"ה טל חזרו בהם מהסכמתם, ואולם בעדותו בפניי שלל זאת מר טל והסביר כי הוא מסכים לכל בנייה שמבצעים הנתבעים בכפוף לכך שיהיה לכך היתר בנייה ובכפוף לכך שלא יחרגו לעבר הגג המצוי מעל העמודה השנייה [ר' פרוטוקול הדיון מיום 10.6.12 עמוד 4 שורות 17-23]. אף האפשרות של גב' טל לחזור בה מהסכמתה מוטלת בספק שכן הנתבעים כבר הוציאו כספים מרובים והסתמכו על ההסכמה, ולפיכך כלל לא ברור שרשאית היתה הגב' טל לחזור בה מהסכמתה [יוער, כי מאחר שהוכח כי בדירת ה"ה טל קיימת הרחבה דומה, איני רואה צורך להאריך בנושא].

78. הנה כי כן, הוכח כי בידי הנתבעים הסכמותיהם של בעלי הזכויות בדירות 1,3,4, ומכאן שבאמתחתם הרוב הקבוע בסעיף 71ב(א) לחוק.

79. האם יש בהרחבה המבוקשת על הגג כדי לפגוע בתובעת

80. כמובא לעיל, התובעת טענה כי הבניה המבוקשת על הגג תפגע בה פעמיים – היא תפגע בה בכך שהיא תמנע ממנה לנצל את זכויות הבניה המוקצות לה ולבנות בקומת המסד, בשל



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מגבלת הגובה בתכנית; ובנוסף היא תפגע בה בכך שהדבר יימנע ממנה ומיתר בעלי הדירות לבנות יחידה נוספת משלהם על הגג.

81. אבחן טענות אלו של התובעת.

82. טענת התובעת שלפיה הבניה המבוקשת על ידי הנתבעים תפגע באפשרותה להרחיב דירתה בהתאם לאחוזי הבנייה המוקצים לה בקומת המסד

83. המחוקק היה ער לפגיעות מסוג אלו והסדיר זאת במסגרת סעיף 71ב(2) לחוק הקובע כי: **"לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בנייה יחסיות של כל בעל דירה לפי סימן זה"**. לאמור, ככל שאכן יש בבניה המבוקשת על ידי בעל דירה מסוים כדי למנוע מבעל דירה אחר להרחיב דירתו בהתאם לזכויות הבנייה היחסיות שלו, לא ניתן יהיה לקבל החלטה המאשרת את ההרחבה המבוקשת לאותו בעל דירה מסוים [ר] לעניין זה גם א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 235-234].

84. והנה, במקרה דנן לית מאן דפליג על כי במסגרת התכניות התקפות [תכנית המתאר לירושלים ותכנית מס' 2696], ניתן לבנות בחלקה שלש קומות לכל היותר. בהינתן זאת, לכאורה, אכן יש בבניה על הגג כדי למנוע מהתובעת לממש את זכויותיה. כך הסביר זאת המומחה מטעם התובעת, מר דן יזרעאלי [ר] עמוד 3 שורות 22-20 לפרוטוקול מיום 24.9.12: **"לגבי קומת המסד, היא לא יכולה כי זה בניגוד לתב"ע, עפ"י התב"ע זה איזור של 2 קומות והתב"ע מאפשרת הקלה בקומה. ברגע שאתם ממשים את הזכויות שלכם לקומה נוספת בגג לא ניתן יהיה להוסיף קומה בקומת המסד..."**.

85. במענה לטענה זו הסבירו הנתבעים, כי הלכה למעשה אין בבנייה המוצעת על הגג כדי לפגוע באפשרויות ההרחבה של התובעת, וזאת משום שהפרשנות המקובלת אצל גורמי התכנון למגבלת הגובה בתכניות כאמור, היא שיש לבחון את הגובה בהתאם לחתך הבניה בשטח הרלוונטי, ובהתעלם משטחי שירות ובכלל זה ממ"ד. לשיטתם, בהתחשב בפרשנות זו של גורמי התכנון, ונוכח העובדה שהבנייה המבוקשת על ידם משתרעת רק על חלק משטח הגג והיא אף כוללת שטחי שירות, לא היא בהרחבת דירתם כדי לגרום לפגיעה כלשהי באפשרות התובעת לנצל את אחוזי הבנייה המוקצים לה ולהרחיב דירתה למסד ולשטחים נוספים בחצר.

86. לאחר שבחנתי את חומר הראיות המונח בפניי ואת הבנייה המבוקשת על ידי הנתבעים, הגעתי למסקנה כי יש להעדיף את עמדת הנתבעים שלפיה מגבלת הגובה בתכנית מתייחסת לחתכי הבנייה, ובהינתן זאת אין בהרחבה המבוקשת כיום על ידי הנתבעים [כ- 50 מ"ר] כדי



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לפגוע באפשרויות שיש לתובעת להרחיב דירתה באופן דומה בקומת הקרקע ובקומת המסד.

87. כך למשל העיד מר דניאל פינצ'י, עובד מחלקת הרישוי בעיריית ירושלים [ר' פרוטוקול הדיון מיום 7.5.13 עמוד 13 שורות 33-30]: **"לפי מה שאני רואה הוא שם בחתך של ה-4 קומות את הממד. ממד אפשר לעשות מתחת כי זה שטח שירות ולא עיקרי. וזה לא יספר בחתכים"**. [ר' גם עדותו בעמוד 14 לפרוטוקול הנ"ל]. כך גם הסביר זאת המומחה מטעם הנתבעים, מר רוזנבלום [שם עמוד 7 שורות 11-7]: **"...אבל בדיקה עכשיו בכל חתך וחתך כך שבכל נקודה לא תהיה חריגה מכמות הקומות שמותרת בתכנית, אותו חתך מדבר על שטח עיקרי ולא על חלקי שירות כמו מדרגות ומחסן ממד או מחסן. יכולים לראות בתשריט שלי שעל חלק קטן יש חפיפה וזה אותו חלק שיש ממד מוצע ולכן לא סופרים את אותו ממד"**. המומחה רוזנבלום אף העיד כי: **"בהחלט לאור הניסיון שיש לי, הסבירות שלא תוכלו לממש את הבנייה למטה שואף לאחוז מזערי. בוצעו עשרות הרחבות עפ"י התב"ע הזאת..."**. [שם עמוד 6 שורות 23-21].

88. אף המומחה מטעם התובעת, מר יזרעאלי, הודה כי הבדיקה נעשית לפי חתכי הבניה, כך שבאופן תיאורטי אין בבניה המוצעת על הגג כדי למנוע מהתובעת מלבצע הרחבה בקומת המסד. מר יזרעאלי הבהיר כדלקמן [ר' פרוטוקול הדיון מיום 24.9.12 עמוד 3 שורות 32-33]:

ש. אני אומר לך שבשטח שמתחת למרפסות המוצעות כיוון שאין קומה נוספת היא תוכל לבנות גם במסד, האם זה נכון?

ת. בתיאוריה היא יכולה כי סופרים את הקומות בחתך, אבל מה שיצא אחרי שהיא תצטרך להוסיף מדרגות, הכל בכפוף לתקנון התכנית אם יש הוראה מיוחדת בבניין".

89. גם מעיון במוצג מ/ש/3 ניתן ללמוד כי לאור הפרשנות המקובלת לתכנית 2696 ביחס למגבלת הגובה, ניתן לערוך תכנית המאפשרת לתובעת להרחיב דירתה בהיקף ניכר של 125 מ"ר, בד בבד עם הרחבת דירת הנתבעים על הגג.

90. מכל המקובץ עולה כי אין בהרחבה שמבקשים הנתבעים לבצע על הגג, כדי למנוע מהתובעת מלנצל את אחוזי הבנייה היחסיים שהוקצו לה ולהרחיב דירתה בקומת הקרקע ובקומת המסד.

91. למען שלמות הנושא אבקש להתייחס לטענה שהועלתה על ידי התובעת בסיכומיה, ושלפיה קיימת טעות בסיסית בחישוב אחוזי הבנייה המוקצים לכל דירה בבית המשותף, שיש בה לשנות מהקביעה שהתובעת יכולה גם היא לנצל את מלוא זכויותיה. טענתה של התובעת בעניין זה היא כי כל החישובים שבוצעו בנוגע לאחוזי הבנייה בחלקה, נערכו בהתאם לאמור



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בסעיף 8ג' לתכנית בניין עיר מס' 2696 הקובע כי לכל דירה יוקצו 125 מ"ר. דא עקא, כך מסבירה התובעת, שסעיף 8ג' מתייחס לחלקות הקטנות מ- 1,000 מ"ר, בעוד ששטח החלקה דנן עולה על 1,000 מ"ר, ולפיכך חל על החלקה סעיף 8ב' לתכנית 2696 המקנה זכויות נוספות לכל דירה ודירה. על פי סעיף זה, זכויות הבניה בחלקה יהיו בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו לאזור מגורים 5, ומאחר ששטח החלקה הוא 1,153 מ"ר, הרי שסך כל זכויות הבניה אמור להיות 576 מ"ר, ובהתאמה – 144 מ"ר לכל דירה ודירה. [ר' נסח הרישום בנוגע לשטח החלקה; כן ר' עדותו של מר פינצ'י בעמוד 14 שורות 40-38 לפרוטוקול מיום 7.5.13 המסביר כי בהתאם לסעיף 8ב' לתכנית 2696 זכויות הבנייה יהיו בשיעור של 50% משטח החלקה].

92. תחילה אעיר, כי עמדה זו של התובעת בדבר היקף אחוזי הבנייה המוקצים לכל דירה ודירה לא הוכחה כדבעי בהליך בפניי, והיא אף בניגוד לעמדתו הראשונית של המומחה מטעמה [ר' עדות המומחה יזרעאלי עמוד 3 שורה 14 לפרוטוקול מיום 24.9.12; בעדותו מאוחר יותר תיקן המומחה את דבריו וטען כי אכן זכויות הבנייה המוקצות אמורות להיגזר משטח החלקה כאמור – ר' דבריו בעמוד 4 שורות 15-8 לפרוטוקול הדין מיום 24.1.13].

93. יתרה מזאת, גם אם ייקבע כי יש לחשב את זכויות הבנייה בהתאם לסעיף 8ב' לתכנית 2696, אין בכך כדי לשנות מתוצאת הדברים אליה הגעתי, וזאת ממספר טעמים. בראש ובראשונה מאחר שבהתאם להודעת הנתבעים הבנייה המתוכננת על ידם כיום משתרעת על שטח של 47 מ"ר בלבד, ובוודאי שאין בה כדי לפגוע באפשרות התובעת לבצע בנייה בהיקף דומה. רוצה לומר: גם אם אכן יוכח שלא יהא באפשרות התובעת להרחיב דירתה בהתאם לכל אחוזי הבנייה שכביכול מוקצים לה, אין בכך כדי למנוע מהנתבעים מלנצל את אחוזי הבניה המוקצים להם לצורך הרחבת דירתם בהיקף אשר לכל הדעות יש בידי התובעת אפשרות לבצע בדירתה. זאת ועוד, התרשמתי כי ניתן יהיה להרחיב את דירת התובעת גם בהיקף העולה על 125 מ"ר, הגם שהדבר ידרוש הקלות כאלה ואחרות מצד גורמי התכנון, ומכאן שגם אם תתקבל הטענה שדירת התובעת ניתנת להרחבה בהיקף גדול יותר מ-125 מ"ר, אין בהרחבה המבוקשת על ידי הנתבעים כדי למנוע מהתובעת להרחיב דירתה בהתאם לזכויותיה היחסיות [ר' לעניין זה עדות המומחה יזרעאלי בעמוד 4 לפרוטוקול מיום 24.9.12 שורות 1-9, וכן עמדתו בעמוד 3 שורות 32-37 לפרוטוקול הנ"ל בעניין האפשרות לקבלת הקלה].

94. סיכומי של דבר, שלא מצאתי כי יש ממש בטענת התובעת שלפיה יש בבקשת הנתבעים להרחיב דירתם על הגג, כדי לפגוע בזכויותיה היחסיות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

95. טענת התובעת שלפיה הרחבת דירת הנתבעים על הגג פוגעת בה מאחר שהיא מונעת את האפשרות להוסיף יחידת דיור על הגג
96. דינה של טענה זו להידחות.
97. כפי שהובא לעיל, תיקון מס' 18 לחוק נועד לצמצם את מצוקת הדיור באמצעות מתן היתר לבעלי הדירות להרחיב דירתם על שטח הרכוש המשותף. מטבע הדברים, ומאחר שההרחבה שהתיר המחוקק היא הרחבה הסמוכה לדירה [ר' ע"א 1462/10 **עטיה נ' שגיא** המוזכר לעיל], הרי שבמקרים רבים רק חלק מבעלי הדירות ייהנו מהאפשרות להרחיב דירתם בהתאם לתיקון מס' 18 לחוק. מובן גם כי באותם מקרים, ההרחבה שתבוצע על ידי בעלי הדירות הזכאים לכך תפגע באפשרותם של יתר בעלי הדירות לעשות שימוש בשטח המשותף, בין היתר, לצורך הקמת יחידת דיור נוספת, ואף על פי כן קבע המחוקק כי בהתקיים הרוב הקבוע בסעיף 71 לחוק, זכאי יהיה בעל דירה הסמוכה לשטח ההרחבה להרחיב את דירתו. ודוק: המחוקק לא התעלם מהפגיעה שעלולה להיגרם ליתר בעלי הדירות, אך בחר לרפאה באמצעות תשלומי האיזון שנקבעו בסעיף 71 לחוק, ולהתיר במקביל את ההרחבה על כל המשתמע מכך. [ר' גם א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 223-224].
98. נמצא אפוא, כי טענה זו של התובעת מעקרת מתוכן את סעיף 71 לחוק, וחוטאת למטרת המחוקק בתיקון מס' 18 אשר העדיף את זכותו של בעל דירה להרחיב דירתו על פני זכותו של בעל דירה אחרת להשתמש בשטח הרכוש המשותף בין היתר לצורך הקמת יחידת דיור חדשה.
99. לאור המוסבר, אין בידי לקבל את טענת התובעת שלפיה יש לאסור על הנתבעים להרחיב דירתם על הגג רק משום שהיא תמנע מהתובעת לבנות יחידת דיור חדשה על הגג.
100. יוסף, כי על פי התכנית שבתוקף [2696] אפשרות זו לבניית יחידת דיור נוספת כלל אינה רלוונטית כיום, שכן בסעיף 8' לתכנית נקבע כי: "לא תורשה הוספת יחידת דיור בגין תוספת הבניה".
101. סיכומו של דבר, שלא מצאתי כי יש בהרחבה המבוקשת על הגג כדי להסב לתובעת פגיעה, שיש בה כדי להצדיק את התניית הבניה בהסכמתה.
102. מאחר שהוכח כי הנתבעים עמדו בהוראות סעיף 71 לחוק, אין צורך של ממש שאדון בטענת התובעת בנוגע לפגיעה בחזות הבית המשותף [שכן די ברוב רגיל של בעלי הדירות כדי לאשר פגיעה בחזיתו של הבית המשותף – ר' למשל: ע"א 515/65, **רבובסקי נ' גלסברג**, פד"י כ(2), 290, ע"א 93/84 **שלמה קדמי נ' יערי קווין**, פ"ד, מ(1), 724]. עם זאת, אני מוצא



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לנכון לציין כי מביקורי במקום התרשמתי שהבנייה המוצעת תואמת את סביבתה בכלל, ואת מראהו של הבית כיום בפרט, ולפיכך גם לגופו של עניין איני מקבל את טענת התובעת בעניין זה [ור' גם סעיפים 21-24 להחלטת ועדת הערר לתכנון ולבניה מיום 30.12.09].

103. הגשרון אותו מבקשים הנתבעים לבנות

104. ביום 18.12.01 הוסף לחוק המקרקעין סעיף 59' הקובע כדלקמן:

(ב) בעל דירה שהוא, שכן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן – התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 – בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;

(2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;

(3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;

(4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה;

(5) בעל הדירה או מי מטעמו, מסר, לא יאוחר מארבעים ימים לפני מועד ביצוע ההתאמה, הודעה מפורטת בכתב לנציגות הבית המשותף אודות הכוונה לבצע את ההתאמה ומהותה; באין נציגות לבית, תומצא הודעה כאמור לכל דירה בבית המשותף.

(ג) (1) ביצוע ההתאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק א' שבתוספת השניה אינו טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.

(2) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

(3) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ג' שבתוספת השניה טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן הדירות בבית המשותף.

105. לאחר שבחנתי את הראיות שהגישו הצדדים, ולא לפני שביקרתי במקום והתרשמתי מהמצב בשטח, הגעתי לכלל מסקנה כי ניתן לאשר את בניית הגשר בהתאם להחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה מיום 30.9.12 (נספח 9 לתצהיר התובעת).

106. הנתבעים הציגו היתר בנייה לגשרון וכן את החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה הנ"ל שקבעה את תוואי הגשר, ובכך מילאו הנתבעים אחר הוראות סעיף 59ג(ב)(1) לחוק.

107. כמו כן, הציגו הנתבעים את אישורו של פרופ' אנדרי קרן - מנהל המחלקה לאי ספיקת לב ומחלות שריר הלב, בבית החולים הדסה ירושלים, על גבי טופס ערוך בהתאם לחלק ד' לתוספת השנייה, המעיד כי הנתבע זקוק לגשרון כדי להגיע לדירתו. אישור זה לא נסתר וממילא הנתבעים עמדו גם בהוראות סעיף 59ג(ב)(2) לחוק.

108. באשר לפגיעה הנטענת - הרי שלאחר שביקרתי במקום הגעתי לאותה מסקנה שאליה הגיעה גם ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה (שגם היא ביקרה במקום), אשר קבעה בהחלטתה מיום 30.9.12 כדלקמן:

"האיזון הנכון הינו כי אכן יקום גשר, אשר יאפשר נגישות בעלי מוגבלויות לדירה. אלא שהגשר לא יהיה במיקומו המוצע בבקשה להיתר אלא ייבנה בצמוד לקיר המחסן הקיים, כאשר זה יתחבר לחדר השינה בדירת המשיב 2. פתרון זה מאזן בין זכויות הצדדים בכך שמחד, הוא מעניק פתרון נגישות לדירת המשיב 2, ומאידך מונע פגיעה בחלונות דירת העוררת. יבואר כי הגשר במיקומו החדש אינו חוסם חלון כלשהו של דירת העוררת, והוא ממוקם מעל פתח הכניסה האחורי בלבד. עוד נציין כי הגשר במיקום זה אינו מהווה פגיעה אדריכלית בהיותו קצר ביותר וצמוד למחסן קיים. לא נעלם מעייננו כי הגשר במיקומו החדש מתחבר לחדר השינה בדירת המשיב 2, ואינו מהווה תכנון אופטימאלי כלפי משיב 2...באיזון בין האינטרסים השונים זהו הפתרון המאוזן ביותר".

109. דברים אלו משקפים באופן מדויק גם את התרשמותי שלי, לאחר שבקרתי במקום, ולפיכך אין לי אלא לקבוע כי גם התנאי המפורט בסעיף 59ג(ב)(3) התקיים.

110. אין מחלוקת כי הנתבעים הם שיישאו בעלות העבודה, ולפיכך אין ספק כי הנתבעים עונים על הדרישה שבסעיף 59ג(ב)(4) לחוק.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

111. ואחרון, סבורני כי בנסיבות העניין יש לראות בנתבעים כמי שקיימו גם את הוראות סעיף 59ג(ב)(5) בדבר הודעות לנציגות או ליתר בעלי הדירות. ראשית, משום שלאורך כל ההליך לא הוברר מי כיהן בנציגות במועד הרלוונטי, ובכל מקרה ההליך דנן כשלעצמו שנוהל בטרם נבנה הגשרון, הבהיר לכל בעלי הדירות את כוונתם של הנתבעים בנוגע לגשרון והעניק להם זמן רב מאוד לדון בנושא ובהשלכותיו.
112. מאחר שבניית גשרון הינה עבודה הנכללת במסגרת העבודות המפורטות בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק [ר' סעיפים 5,8-3 לחלק ב' לתוספת השנייה], ובהתאם לסעיף 59ג(ג)(2), על הנתבעים לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות לבנייתו.
113. מהחומר המונח בפניי עולה כי בעלי הזכויות בדירות 1,3 (ה"ה טל וה"ה בן ישי) הסכימו לבניית הגשרון ואף חתמו על תכניות הבניה שבהן מופיע הגשרון, וממילא בידי הנתבעים הרוב הדרוש להם. [לעניין הסכמותיהם של ה"ה בן ישי וה"ה טל – ר' האמור לעיל בפרק העוסק בהרחבה על הגג. בעניין זה יוער כי גם אם היתה מתקבלת טענת התובעת בעניין חזרתה מהסכמה של גב' טל, הרי שעדיין בידי הנתבעים הרוב הדרוש לבניית הגשרון, וזאת לאור הסכמתו של מר טל כמפורט לעיל].
114. הנה כי כן, הנתבעים רשאים להקים את הגשרון כמפורט בהחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה, וזאת בהתאם לסעיף 59ג לחוק המקרקעין.

1. הערה בטרם סיום

115. צר לי על כי הצדדים בחרו לצעוד בהליך דנן בדרך ארוכה ופתלתלה, ולא שעו להפצרותיי להגיע לתוצאה שיש בה כדי להיטיב עם שניהם. גם עתה, בעת חתימת פסק הדין, אני סבור כי טוב יעשו הצדדים אם יגיעו להבנות על בסיס המתווה שהוצע במסגרת ההליך, שיש בו כדי להשכין שלום ולגשר על התהום העמוקה שנפערה ביניהם.

2. סיכום

116. התביעה למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבנות בחזית הבית המשותף בהתאם להיתר הבניה מושא הדיון, מתקבלת. בתוך כך, על הנתבעים להשיב לקדמותו את המצב בחזית הבית המשותף, ובכלל זה, ליישר את הקרקע ולשקם את הגינה והגדר שנהרסו. על הנתבעים לבצע את כל הפעולות הדרושות לשיקום השטח כאמור בתוך 60 ימים, למעט פעולות של שתילה ונטיעה בגינה, אשר רשאים הנתבעים לדחותן לאחר שנת השמיטה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

117. התביעה למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להרחיב דירתם על הגג ולבנות את הגשרון, בהתאם להיתר הבניה מושא הדיון, נדחית.

118. למען הסר ספק יצוין, כי ההיתר הניתן לנתבעים בפסק דין זה להמשיך את העבודות בגג הינו אך ורק לשם הרחבת דירתם ולא לשם הקמת יחידת דיור נפרדת.

119. צו המניעה הזמני מבוטל.

120. לאור התוצאה אליה הגעתי, במסגרתה חלק מהתביעה התקבל וחלקה האחר נדחה, כמו גם נוכח ההוצאות המרובות שכבר היו לצדדים במסגרת ההליך, וכן לאור האירועים שפקדו את הצדדים במהלכו, הגעתי לכלל מסקנה כי אין זה נכון לפסוק הוצאות כנגד מי מהם.

121. מאחר שהגשרון נבנה בהתאם לסעיף 59 לחוק, על כל המשתמע מכך, ועל מנת שלא ייטעה צד ג', אני מורה על רישום הערה בדירת הנתבעים לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין בדבר קיומו של פסק הדין. רשמת המקרקעין תרשום אפוא הערה בגין פסק הדין בגוש 30143 חלקה 13 תת חלקה 4, כאשר בגוף ההערה יירשם כי אין בפסק הדין כדי למנוע ביצוע עסקאות ופעולות כלשהן בדירה.

ניתן היום, י"ג טבת תשע"ה, 04 ינואר 2015, בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. חייזר

מפקח על רישום המקרקעין